

1504364-19.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76

- Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico

ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato

da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504364-19.2022.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504364-19.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de
Ocorrência - 2041295/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 22991424 - 27º D.P. IBIRAPUERA,
AI8903-1/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONAN CUNHA DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 259/22

Vistos.

LEONAN CUNHA DIAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do
artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/06, porque consta que no
dia 13 de fevereiro de 2.022, por volta de 22h, à Rua Maracaju, 20, Vila Mariana,
São Paulo, trazia consigo, para consumo de terceiros, cerca de 59.6g de cocaína,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida à fl. 87.

Defesa preliminar devidamente apresentada.

Durante a instrução processual, foram ouvidas através do sistema de áudio e vídeo,
duas testemunhas de acusação, e os réus foram interrogados.

Em debates, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos
exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do

crime.

A defesa, requereu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento das excludentes da desistência voluntária, afastamento da agravante, pena mínima, redução no máximo, com regime mais brando, substituição e recurso em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime veio bem estampada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, dando conta das 06 cápsulas de cocaína, localizadas e apreendidas em poder do réu.

Em complementação, o Laudo químico toxicológico de fls. 140/142, atestou que as substâncias localizadas em poder do acusado eram positivas para cocaína.

Na fase inquisitiva o réu permaneceu calado, fls. 12.

Em seu interrogatório judicial, o acusado confessou que eu estava indo para Porto Seguro, para encontrar com uma amiga. Eu estava procurando emprego, e no ônibus eu conheci um rapaz, e conversando com ele, disse que procurava emprego na área da engenharia civil, que era minha área. Ele disse que estava vindo da Espanha, e me passou o contato de outra pessoa. Em São Paulo, essa pessoa me colocou em um hotel, e me fez a proposta, de engolir drogas para levar para Lisboa, pelo valor de vinte mil reais. Eu não aceitei a proposta, ele começou a me oferecer água, eu bebi, ele começou a fazer terror psicológico. Eu consegui ingerir apenas seis capsulas, e comecei a passar mal. Eu disse que não conseguia mais engolir que estava passando mal. Ele disse que ia me levar para outro lugar, eu estava me sentido meio drogado. No trajeto, eu pulei do carro, fiquei nessa situação por dois dias, dormi na rua. Foi quando entrei no restaurante e consegui expelir as drogas. Eu pensei em entrar em contato para recuperar minha mala e devolver as drogas. Porém no restaurante, eles chamaram a policia e eu acabei sendo preso com as drogas. Sou estudante de engenharia civil. Nunca fui preso antes e não conhecia os policiais.

É certo que a confissão sozinha não se presta a sustentar todo o édito condenatório. Mas é certo também que quando vem acompanhada dos demais elementos probatórios, como no presente caso, pode e deve ser considerada como útil elemento de convicção.

É certo que a quantidade da droga por si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, as circunstâncias dos autos, tais como, a grande quantidade do tipo de droga encontrada, a forma como estavam acondicionadas, em capsulas ingeridas e expelidas pelo réu, prontas para serem transportadas, somado ao relato firme dos policiais, e à própria confissão do réu, não deixam dúvidas acerca da traficância.

E assim é porque os policiais militares responsáveis pela prisão do acusado, Marcos Beltrão Martins e Lidice Coelho Gomes, ouvidos em Juízo, relataram de forma firme, segura e em uma só voz que fomos acionados para atender uma averiguação, proque o proprietário do estabelecimento desconfiou da situação em que o réu estava muito tempo no banheiro e chamou a gente. Quando chegamos, o réu já estava fora do banheiro com uma sacola e esses pinos dentro. Ele de pronto confessou que havia sido contratado por uma quadrilha, para engolir 90 capsulas de cocaína para transportar para Portugal. Ele disse que não conseguiu ingerir toda a droga, mas apenas algumas cápsulas. Então quando ele avisou a quadrilha que não havia conseguido engolir toda a droga, o negócio foi desfeito, ele disse que foi sequestrado, mas conseguiu pular do carro e se escondeu no local. Ele chegou a dizer que a quadrilha havia ficado com todos os seus pertences. Com o réu foram encontradas apenas seis cápsulas, que ele conseguiu expelir. As demais não foram encontradas. Reconheceram o réu e não o conheciam anteriormente.

Os policiais narraram com segurança e precisão como se deu a prisão do acusado, relatando todos os detalhes, desde a chegada ao local, em razão de averiguação de denúncia com uma pessoa trancada num banheiro em estabelecimento comercial por muito tempo, a chegada ao local com o réu já saído do banheiro e portando uma

sacola em mãos, o encontro das cápsulas de cocaína na sacola, a confissão informal do réu ao afirmar aos policiais que transportaria a Portugal cerca de 90 cápsulas de cocaína, mas que não conseguiu ingerir o total, razão pela qual o negócio foi desfeito, alegando que os contratantes mandaram busca-lo para devolver as cápsulas e por isso decidiu pular do carro em movimento e foi ao restaurante para expelir as drogas, até final detenção e prisão.

Mister se faz, neste momento, dizer que o testemunho dos policiais deve ser valorado como de qualquer outra pessoa, não havendo motivo para de pronto depreciá-lo. Com efeito, há muito tempo já se encontra superada a sustentação de ser insuficiente a prova policial.

Neste sentido: "Os policiais militares como qualquer outra pessoa não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial." (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 153.694-3 - São Paulo - 26.09.94).

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Tóxico. Depoimento prestado por policial. Prova firme e coerente. Apreensão em fiscalização de Trânsito e de rotina. Circunstância que justifica o não arrolamento de testemunha alheia ao quadro policial. Recurso não provido". (Apelação criminal. 126.697-3, rel. Des. Álvaro Cury. RJTJESP n. 138/451).

Em que pesem os argumentos da Duta Defensoria Pública, alegando em síntese que os policiais não lograram êxito na prova da traficância, vejo nos autos que todas as circunstâncias apontam em sentido contrário.

Neste contexto, em vista da grande quantidade de drogas encontradas em poder do réu, a forma como estavam embaladas, de forma individualizada, prontas para transporte, e ainda o relato seguro e firme por parte dos policiais, resta inexoravelmente comprovado que mantinham substância tóxica para consumo e entrega a terceiros.

No mais, nem se cogite que a ausência de descrição de ato de venda, compra ou qualquer outro que indicasse atividade de mercancia, pudesse vir a inocentar o acusado da imputação descrita na denúncia ou mesmo possibilitar a desclassificação para uso próprio.

E isso porque, tratando-se de tipo penal tido como de conteúdo múltiplo ou variado, preencheu o réu um dos núcleos do tipo denunciado, sendo pois, impossível a absolvição ou desclassificação pretendida pela defesa.

Para a condenação, na hipótese dos autos, é absolutamente irrelevante não ter o agente, sido surpreendido no ato da venda, bastando que haja indicativos outros, como forma de acondicionamento da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76 - Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros indicativos de fim de mercancia - Recurso não provido. (Ap. 296.182-3, São Paulo, 4ª C., rel. Canellas de Godoy, 25.04.2000, v.u.). Destarte, não evidenciou-se qualquer situação que pudesse excluir o crime ou isentar os réus das penas.

Apenas um reparo merece a peça acusatória. Não restou comprovado a transnacionalidade do delito.

E isso porque, muito embora tenha o próprio réu confessado que ingeriu as drogas para fins de transporte internacional, fato é que nem mesmo chegou a dar início à execução de tal conduta.

Tanto é assim que nem chegou a engolir toda a droga que seria transportada, tendo sido detido quando expelia as drogas de seu corpo, de sorte que não teria como transporta-las para fora do país.

Nesse sentido, a tese defensiva no que tange à desistência voluntária pode ser reconhecido com relação à agravante, mas não com relação ao crime de tráfico em si.

E isso porque, com relação à prática do crime de tráfico, não houve desistência

voluntária por parte do acusado, eis que foi detido em poder de considerável quantidade de drogas. A questão é objetiva e prescinde de maiores divagações a respeito. O réu foi preso em flagrante em poder de capsulas de cocaína, para fins de transporte e venda. Sua conduta amoldou-se perfeitamente ao tipo legal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos, de maneira que a tese defensiva não prospera. Passo a dosar a pena.

Verificando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, atento dolo normal à espécie. O acusado é primário e não ostenta antecedentes criminais, assim, nesta primeira fase fixo sua pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na hipótese dos autos, forçoso de faz reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos. E isso porque o acusado primário, sem quaisquer antecedentes, confessou a autoria delitiva, e não há um indício sequer a demonstrar que faça parte de alguma organização criminosa. Assim, considerando-se as circunstâncias específicas destes autos e das condições pessoais do réu, reduzo a pena no máximo previsto, 2/3, para, não havendo outras circunstâncias torna-la definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias multa.

O valor do dia multa será o mínimo legal.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar LEONAN CUNHA DIAS, como incurso nas penas do artigo 33, § 4º, da Lei nº11.343/06, a cumprir, em regime aberto, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias multa.

Na hipótese específica destes autos, o regime aberto se justifica tendo em vista que o réu é primário, sem qualquer mácula em sua vida, foi solto no curso do processo e comprovou que encontra-se trabalhando, sendo que faze-lo retornar aos sistemas carcerários revela medida excessivamente drástica como forma de repressão e retribuição.

De outro giro, não é possível a aplicação de qualquer substituição, porque o escopo do legislador foi beneficiar delitos que não mantém repercussão na sociedade, o que não é o caso do tráfico de drogas, cujo promovente deve ser segregado do convívio social. Não se pode perder de vista ainda, que o artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos prevê, de forma expressa a vedação da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É certo que o STF, nos autos do HC 97256/RS, cujo relator foi o Ministro Carlos Ayres Brito, declarou de forma incidental a inconstitucionalidade da vedação em apreço. Mas é certo também que referida decisão foi proferida por maioria apertada (6x4) e reconhecida, apenas na hipótese específica daqueles autos, alcançando tão somente, as partes que ali figuraram.

No mesmo sentido, foi a recente decisão proferida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 0090150-57.2012.8.26.0050, cujo teor passo a descrever:

“Como bem colocado pelo Ilustre Desembargador Souza Nery: “inviável a aplicação da pena alternativa. Não só pela própria hediondez do crime, que recomenda maior rigor no escarmento, mas também porque a Lei nº 11.343/06 expressamente veda a benesse aos traficantes, nos precisos termos do que dispõe o seu artigo 44, caput. Tal dispositivo legal foi editado pelos poderes competentes, goza de presunção de constitucionalidade e não parece ofender a Constituição de República de modo franco e direto. Não desconheço que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Excelso Pretório (HC 97.256) no ano de 2010, mas essa decisão foi tomada por maioria apertada (6 x 4) e valeu somente para o processo julgado (incidenter tantum).”

Desta forma, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade erga omnes, de maneira que, em cada caso concreto, a vedação imposta pela Lei de Tóxicos, pode ser aplicada e reconhecida.

Oficie-se à autoridade policial, oportunamente, para incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de abril de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA